

1500674-67.2020.8.26.0594

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Cláudio Augusto Saad Abujamra

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/07/2022

... de afastar de si a responsabilidade pelo crime de tráfico, pois sabia que, tendo sido flagrado em local conhecido como ponto de tráfico, parado, na posse de dinheiro e de 05 pedras de crack, 13 pinos de cocaína e três porções de maconha, certamente concluiria a Justiça, e com acerto, que ele estava realizando tráfico. O magistrado criminal deve estar atento à fala ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

3ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500674-67.2020.8.26.0594 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500674-67.2020.8.26.0594

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2170003/2020 - CENTRAL

POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 12388171 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 9341/20/404 -

CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 2170003 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RENAN ABRAO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cláudio Augusto Saad Abujamra

Vistos.

RENAN ABRAO DA SILVA foi dado como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, porque, no dia 13 de julho de 2.020, por volta das 09h34, na rua Waldemar Gregório de Moraes, quadra 03, Parque São João, nesta cidade, trazia consigo, para fins de tráfico, 1,07 gramas de crack, 2,53 gramas de cocaína e 3,90 gramas de maconha, droga que determina dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Notificado (fls. 259), o réu apresentou a defesa preliminar de fls. 265/266. A denúncia foi recebida por despacho datado de 13 de setembro de 2.021 (fls. 273/275).

Em audiência, foram ouvidas testemunhas e o réu foi interrogado (fls. 308 e 321/336).

Em alegações finais, o representante do Ministério Público pediu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia (fls. 318/320).

Já a defesa técnica se manifestou a fls. 344/376, alegando que: 1)- a situação de rua em que vivia o acusado, o trabalho de coleta de recicláveis e a ajuda de familiares e terceiros inviabilizavam que ele conseguisse comercializar drogas, pois não lhe seria confiada a posse de entorpecentes; 2)- é natural a presença de um usuário em ponto de tráfico; 3)- o réu nunca foi abordado com drogas ou outro ilícito que indicasse ser traficante; 4)- o dinheiro não foi apreendido e nem apresentado à autoridade policial, o que coloca em dúvida os depoimentos dos policiais; 5)- os depoimentos policiais não são suficientes para a condenação; 6)- as drogas se destinariam ao consumo próprio, devendo a conduta ser desclassificada; 4)- o réu faz jus à causa de diminuição de pena do art. 33, §4º da Lei 11.343/06. Pediu a absolvição e, alternativamente, a desclassificação da conduta inicialmente imputada para a previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, a fixação do regime inicial aberto, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o relatório. Passo a decidir.

A materialidade do crime está demonstrada pelo auto de apreensão de fls. 16 e pelo laudo pericial de fls. 138/141 (cinco porções de crack com peso de 1,07 gramas, treze porções de cocaína com peso de 2,53 gramas e três porções de maconha com peso de 3,90 gramas).

A autoria e o intuito de traficância derivam da prova oral e das circunstâncias do caso e devem ser atribuídos ao acusado.

Interrogado na polícia, ele declarou já ter tido envolvimento com tráfico quando menor de idade. Atualmente, trabalha como mecânico numa oficina, sem registro. Não tem mais envolvimento com tráfico. A droga não lhe pertencia. Estava numa festa na casa de parentes quando abordado. Tinha acabado de chegar no local da festa. A droga não foi encontrada em sua posse (fls. 09).

Em juízo, a testemunha Fabio Luis dos Santos, policial militar, afirmou que estava em patrulhamento no Parque Viaduto e, no local do fato, conhecido como ponto de tráfico, visualizou o réu. Ao ver a viatura, o acusado demonstrou nervosismo. Ele foi abordado e, em seu poder, foram encontrados entre dez e quinze pinos de cocaína, três ou quatro pedras de crack, três ou quatro porções de maconha e dois reais em dinheiro. Indagado, ele confessou a prática do tráfico. Quando avistado, o réu estava parado na esquina, onde situado o ponto de tráfico. Não se lembra se o valor foi apreendido na delegacia. Não havia pessoas próximas do réu quando da abordagem (fls. 321/324).

A testemunha Weverton Batista de Souza, também policial militar, disse que estava em patrulhamento em local que é conhecido como ponto de tráfico. O réu viu a viatura policial e tentou se evadir, acessando um terreno. Contudo, ele foi abordado. Em busca pessoal, constatou que o acusado portava drogas e dinheiro. Ele confessou o tráfico. Não se recorda da quantia em dinheiro. Ele portava maconha, crack e cocaína, todas em porções prontas para venda. Indagado, o réu explicou que vendia drogas para sustentar seu próprio vício. O local é ponto de tráfico. Não conhecia o acusado mas, após o fato, já o viu no mesmo local. Em outras oportunidades nas quais o abordou, ele disse que estava de passagem. Já o abordou inclusive em outro local também conhecido como ponto de tráfico. Na abordagem, o réu estava acompanhado. O que ensejou a abordagem foi fato relacionado à outra pessoa que com ele estava. Naquela ocasião, nada de ilícito foi encontrado. O acusado mora no mesmo bairro. Não se lembra se, na data do fato, havia outras pessoas próximas. Não se recorda também se o dinheiro estava junto da droga (fls. 325/330).

Interrogado em juízo, o réu negou a prática do tráfico. Dirigiu-se ao local para comprar drogas. O rapaz que lhe vendeu entorpecente correu e deixou a droga para trás. A viatura não viu esse rapaz. Tinha consigo apenas duas "paradas" em seu bolso, as quais havia comprado daquele traficante. Na época, vivia em situação de rua. Catava recicláveis e ficava na casa de sua mãe. O pessoal o apoiava para buscar tratamento para sair das drogas. Com o dinheiro da venda de recicláveis,

comprava entorpecente. Fez tratamento depois, no período de seis meses, no estabelecimento Bom Pastor. Já foi internado. Vai fazer duas semanas que concluiu o tratamento. Desde então, não mais usou droga. Atualmente, mora com seus pais. Faz bicos de pintura com seu pai, mas não de forma fixa (fls. 331/335).

Diante de tal conjunto probatório, impõe-se a condenação do acusado nos termos da denúncia, não merecendo guarida as teses expostas nas alegações finais produzidas em sua defesa.

A prática do delito foi confirmada pelos depoimentos insuspeitos de dois policiais militares, segundo os quais o réu trazia consigo porções de cocaína, maconha e crack, bem como pequena quantia em dinheiro, tendo ele confessado informalmente a traficância.

As afirmações dos policiais se afiguram firmes, coerentes, uniformes e comedidas ou sem tendências para o exagero, merecendo, por isso, serem tidas como expressão da verdade.

De resto, a jurisprudência já assentou a validade da prova consistente em depoimentos de policiais.

À propósito:

"Não se pode presumir em policiais ouvidos como testemunha a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecente por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus depoimentos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição." (RT 610/369).

Em igual sentido:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-la pelo só fato de emanar de agentes estatais, incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal." (STF, D.J. 18/10/96, Habeas Corpus n. 73.518-5 São Paulo, rel. Min. Celso de Mello).

Não bastasse, a experiência tem demonstrado que, quando arroladas como testemunhas de tráfico pessoas de fora dos quadros da polícia, elas invariavelmente não dizem a verdade em juízo, pois não querem se expor a delatar publicamente um traficante, possivelmente com medo de eventuais represálias, ou mesmo por terem algum vínculo de intimidade ou amizade com a pessoa processada.

Logo, o fato descrito na denúncia e respectiva autoria estão bem comprovados.

Por outro lado, não paira dúvida de que o acusado estava praticando o tráfico.

É certo que, em juízo, ele relatou portar apenas duas porções de entorpecente, adquiridas pouco antes da abordagem e destinadas ao seu consumo.

Não menos certo, porém, é que, quando ouvido em solo policial, deu versão distinta, dizendo que estava numa festa na casa de parentes e que não portava nenhum entorpecente.

Prosseguindo, o réu faltou com a verdade ao dizer que tinha consigo apenas duas "paradas" no bolso.

Isto porque, conforme depoimentos dos policiais militares, de cuja veracidade não se duvida, havia muito mais do que apenas duas porções de entorpecente em poder do acusado.

Tem-se, pois, que o réu faltou com a verdade em juízo com o propósito claro e deliberado de afastar de si a responsabilidade pelo crime de tráfico, pois sabia que, tendo sido flagrado em local conhecido como ponto de tráfico, parado, na posse de dinheiro e de 05 pedras de crack, 13 pinos de cocaína e três porções de maconha, certamente concluiria a Justiça, e com acerto, que ele estava realizando tráfico. O magistrado criminal deve estar atento à fala do acusado que nega a verdade, podendo utilizar tal circunstância para formar sua convicção.

Nesse sentido:

"Não se olvide que o parágrafo único do art. 186 do Código de Processo Penal, adotando o princípio do nemo tenetur se detegere, previsto na Constituição Federal, determina que o silêncio do acusado não poderá ser considerado em seu desfavor em processo criminal; todavia, as inverdades pode ele proferidas em interrogatório judicial constituem-se em mais um elemento a ser considerado pelo Magistrado no

momento da formação de sua convicção. Nesse sentido, ponderou o Eminentíssimo Desembargador José Raul Gavião de Almeida que '... Se o réu optar por falar, no interrogatório, deverá medir suas palavras, porque elas poderão ser utilizadas também em seu desfavor. É o que ocorre na hipótese do acusado apresentar versão contrária ao convincente conjunto probatório. Identificado que faltou com a verdade, esse comportamento e o teor da inexatidão podem ser considerados pelo julgador, pois não existe direito à mentira, como não há a correspondente obrigação de ignorar a inverdade' (TJSP, 6ª Câmara de Direito Criminal, Apelação n. 990.10.390742-6, voto n. 10.943)." (em TJSP, Apelação n. 0029345-41.2013.8.26.0071, rel. Silmar Fernandes, j. 13/11/2015).

Ademais, concorda-se com a defesa no ponto em que diz ser natural a presença de usuário de droga em ponto de tráfico.

O que não é natural, porém, é a presença em local da espécie de um usuário, parado, na posse de um total de vinte e uma porções de entorpecentes de três espécies distintas.

É que, ali permanecendo em tais condições, um usuário poderia não somente ser abordado pela polícia e confundido com um traficante, como também poderia vir a ser alvo de subtração da relevante quantidade de droga adquirida.

Certamente, para um indivíduo morador de rua e catador de recicláveis, a perda de vinte e uma porções de entorpecentes, seja por apreensão, seja por subtração, significaria duro golpe para suas finanças e para seu vício.

Enfim, a conduta de permanecer estático em ponto de tráfico e na posse de nada menos do que vinte e uma porções de entorpecentes de três espécies distintas tem muito mais a ver com a postura de um traficante, que fica no local à espera de consumidores.

Não é possível crer, pois, que o acusado estava parado onde foi abordado na condição de mero usuário.

Acresça-se, mais, que o fato de ter sido encontrado dinheiro em poder do acusado e de o numerário não ter sido apreendido formalmente na delegacia de polícia não retira a credibilidade dos depoimentos dos policiais.

Isto porque, segundo o policial militar Fábio Luis, a quantia em questão consistiu em apenas dois reais.

Não é razoável supor que os policiais tivessem corrido o risco de subtrair o dinheiro para obter tão parco benefício (um real para cada um dos dois).

Outrossim, fossem eles profissionais desonestos e dados a furta-lo numerário das pessoas que abordam, certamente teriam tomado todo o cuidado para, em juízo, não mencionar que encontraram dinheiro em poder do suspeito.

Nessa ordem de ideias, outro destino, que não criminoso, pode ter tido o dinheiro encontrado com o réu, inclusive a própria restituição a familiar seu que tivesse se dirigido à delegacia de polícia por ocasião da prisão.

De resto, cabe observar que o art. 33, caput, da Lei Antidrogas define crime de conteúdo múltiplo e de perigo abstrato.

Dessa forma, basta que o agente incorra em qualquer dos verbos ali descritos, desde que sem a finalidade de consumo da droga, para que o delito de tráfico reste caracterizado.

Não é indispensável, assim, que o agente seja flagrado em pleno ato de mercancia de droga, sendo suficiente que a traga consigo (conforme descrito na denúncia e comprovado na instrução).

Destarte, não há como absolver, e nem mesmo como desclassificar a conduta para a prevista no art. 28 da Lei Antidrogas.

Ao contrário, a condenação na forma proposta na denúncia é medida de justiça.

Passa-se à aplicação da pena.

O réu é primário e não registra antecedentes (fls. 43/44).

Diante disso, fixa-se a pena base em cinco anos de reclusão, mais quinhentos dias-multa.

Deve ser aplicado o privilégio previsto no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas.

Destaque-se que a quantidade de droga apreendida não era das mais elevadas, não sendo possível inferir, a partir daí, que o réu se dedicava a atividade criminosa. Outrossim, nenhum outro elemento de convicção permite a segura conclusão de que se

está diante, aqui, de agente que se dedicava a atividade criminosa ou que integrava organização criminosa.

Afigura-se justo deferir a diminuição no grau máximo de dois terços, tendo em vista que as quantidades de drogas e de dinheiro apreendidas não foram das mais elevadas. Destarte, a pena resulta em um ano e oito meses de reclusão, mais cento e sessenta e seis dias-multa.

Não havendo outras modificadoras, tais penas são as definitivas.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena para o tráfico, deve-se ponderar que, no julgamento do HC n. 111.840/ES, realizado em sessão extraordinária do dia 27/06/2012, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/90, com a nova redação dada pela Lei n. 11.464/07, afastando, assim, a obrigatoriedade de imposição do regime inicial fechado para os condenados pela prática de crimes hediondos e outros a eles equiparados (os dados são do HC n. 312.654-SP, STJ, rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, j. 12/02/2015).

Ainda, no julgamento do Habeas Corpus nº 137458/SP, o Ministro Gilmar Mendes assim dissertou:

"Destaco que a jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual a hediondez ou a gravidade abstrata do delito não obriga, por si só, o regime prisional mais gravoso, pois o juízo, em atenção aos princípios constitucionais da individualização da pena e da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, deve motivar o regime imposto observando a singularidade do caso concreto, atentando-se aos preceitos estabelecidos no art. 33, § 2º, do Código Penal. Assim, não sendo a paciente reincidente, nem tendo contra si circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59, CP), a hediondez do crime não constitui motivação idônea a justificar a fixação do regime mais gravoso. Fixo, ainda, o regime aberto de início do cumprimento da pena".

Assim, ausente a obrigatoriedade de fixação do regime inicial fechado para o tráfico, cabe analisar as circunstâncias do caso concreto, a fim de se definir o regime no qual o acusado começará a cumprir a sanção.

Considerando as circunstâncias expostas (primariedade, ausência de antecedentes, pequenas quantidades de droga e de dinheiro), fixa-se o regime inicial aberto. Levando em conta as circunstâncias judiciais favoráveis, conforme antes apontado, e, ainda, o fato de as quantidades de droga e dinheiro não serem das mais elevadas, entende-se cabível, no caso, a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, na forma do art. 44 do Código Penal.

Há orientação jurisprudencial nesse sentido:

"Tráfico de drogas. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Elementos de prova suficientes para a procedência da ação penal. Condenação mantida. Pena-base fixada no mínimo legal. Causa de aumento, prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas, que não se afigurou. Afastamento. Réus que preenchem os requisitos para a redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Circunstâncias do crime que tornam proporcional a diminuição na fração máxima de 2/3. Fixação do regime fechado para início de cumprimento da pena. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Admissibilidade. Inconstitucionalidade das vedações da Lei 11.343/06. Violação ao princípio da individualização da pena (art. 5º, inciso XLVI, da CF). Precedentes do STF e do STJ. Conversão, ex officio, da pena reclusiva em restritiva de direitos: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. Inteligência do artigo 44, § 2º, parte final, do CP. Detração determinada. Analogia ao artigo 42 do CP. Apelo parcialmente provido para esses fins. (TJSP, Apelação n. 0070062-66.2010.8.26.0050, rel. Otávio de Almeida Toledo, j. 13/12/2011).

E ainda:

"Entorpecente Absolvição ou Desclassificação - Impossibilidade - Provas seguras que demonstram a prática do delito de tráfico. Penas fixadas no mínimo e aplicado redutor previsto no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 no percentual de 1/5 - Redução em 2/3 Possibilidade. Penas. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Cabimento. Regime prisional inicial fechado Fixação conforme preceitua o § 1º do artigo 2º da Lei nº 8.072/90, com a redação dada pela

Lei nº 11.464/07 Apelação do réu provida parcialmente." (TJSP, Apelação n. 0006628-72.2010.8.26.0319, rel. Pedro Menin, j. 10/04/2012).

Assim, deve a pena privativa de liberdade ser substituída por duas penas restritivas de direitos, uma consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo tempo das penas aplicada, e outra, em prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo, em favor de entidade pública ou privada com destinação social, a ser definida em execução.

O valor do dia-multa será calculado no piso mínimo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, para condenar o acusado Renan Abrão da Silva como incurso nas penas do artigo 33, caput e §4º, da Lei 11.343/06, a cumprir um ano e oito meses de reclusão, em regime inicial aberto, e a pagar cento e sessenta e seis dias-multa, calculado o valor do dia multa no piso mínimo, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, uma consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da pena aplicada, e outra, em prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo, em favor de entidade pública ou privada com destinação social, a ser definida em execução. Oportunamente, anote-se a condenação no sistema informatizado.

P.R.I.

Bauru, 08 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA